

1502670-22.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297841/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21150787 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3485/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2297841

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502670-22.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502670-22.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297841/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 21150787 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 3485/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2297841

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

João Vitor Marques da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 01 de novembro de 2021, por volta das 15h59, na Rua Luis Tarifa Vargas, 270, Bairro Machado, Franco da Rocha/SP, nas imediações da E. E. Professor Benedito, neste município e comarca de Franco da Rocha/SP, o Réu trazia consigo, sem autorização e em desacordo determinação legal, drogas, a saber: a) 62 porções de cocaína e b) 56 pedras de crack, todas embaladas e prontas a mercância, além da

quantia de R\$ 40,00 em notas trocadas, típicas do tráfico de entorpecentes e produto da sua atividade ilícita.

Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 16/20.

A denúncia foi recebida à fl. 95, em 09 de novembro de 2021.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 114/115.

Regularmente citado e notificado (fl. 118), o Réu apresentou defesa prévia à fl. 123/124.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 140/142.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Wagner Aparecido de Santana Leite e Daniel Nonato de Souza, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 187/191 e 198/230, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No que se refere à alegação de nulidade suscitada pela Defesa, essa se confunde com o mérito, sendo com este analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

03/07, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 14 e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 16/20 e fls. 140/142, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Daniel Nonato de Souza, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando avistaram o Réu, próximo a uma escola. Estava tenso e com uma sacola nas mãos. O declarante e seu parceiro foram, então, em sua direção, momento em que ele tentou se evadir do local. Conseguiram alcançá-lo e encontraram, no interior da sacola, cocaína e crack.

No mesmo sentido, a testemunha Wagner Aparecido de Santana Leite, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, por local conhecido pela prática de venda de entorpecentes, avistaram o acusado com sacola em mãos. Ele esboçou certo nervosismo, tentando, em seguida, se evadir do local. Conseguiram detê-lo e encontraram cocaína e crack no interior da sacola. Não se recorda se havia aulas na escola próxima ao local, no dia da abordagem.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que esse se encontrava em local conhecido pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, em posse de sacola, tendo empreendido fuga logo após avistar os agentes públicos -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que não foram trazidos motivos idôneos para que fosse realizada eventual criminalização infundada pelas testemunhas, sendo certo que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, o Réu, em interrogatório judicial, aduziu que a presente acusação é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava realmente traficando drogas quando foi abordado pelos guardas municipais. Asseverou, contudo, que não estava perto de escola enquanto o fazia.

Destarte, não há provas nos autos contrárias à presente acusação.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes, após visualizarem o Réu em posse de sacola, em local conhecido pela prática de compra e venda de drogas.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

"Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador:

16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (conforme auto de apreensão/exibição de fl. 14, em mais de cem unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas, é conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na posse, pelo Réu, de bolsa com drogas e imediata fuga, em local previamente denunciado como sendo ponto de venda de entorpecentes – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como a ausência de alegação pelo Réu neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase, inexistem provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade de droga (68,34g brutos – fls. 17/18) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço como pena-base 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Anoto que atos praticados pelo Réu antes de atingir a maioridade penal não podem influir negativamente na aplicação da pena pela prática de crime, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base. 2. Há impropriedade na majoração da pena-base pela consideração negativa da personalidade do agente em razão da prévia prática de atos infracionais, pois é impossível exacerbar a reprimenda criminal com base em passagens pela Vara da Infância. 3. (...). 7. Recurso especial provido em parte”. (STJ; REsp 1702051/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Na segunda fase, incide à espécie a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), tendo em vista que o Réu assumiu integralmente a prática delitiva. No entanto, deixo de reduzir a pena por essa já se encontrar em seu mínimo legal – inteligência do enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Assim, pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto a prática do crime de tráfico de drogas ocorria a cerca de 80 (oitenta) metros da Escola Estadual Professor Benedito Aparecido Tavares (consoante se depreende do sítio eletrônico Google Maps), por volta de 16h em uma

segunda-feira, ou seja, nas imediações de estabelecimento de ensino em horário escolar, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda, em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes ao tempo do crime (certidão de fls. 114/115), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Apesar de o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispor que a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena – sendo possível a compreensão de que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos –, entendo ser necessário que haja, ao menos, sentença condenatória proferida em outro processo ou a verificação de situações evidentes, tais quais diversas prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo, de modo a impedir a incidência da minorante em questão.

Como nos autos do processo nº 1501303-60.2021.8.26.0544 não houve condenação do Réu nem em primeira instância e não há provas neste feito que comprovem prisões reiteradas anteriormente aos fatos em questão, não é possível aferir, com algum grau de certeza, que este, de fato, se dedica à prática de atividades ilícitas. Em outras palavras, inexistindo sequer condenação em primeiro grau de jurisdição, a presunção de não culpabilidade do acusado permanece hígida, não sendo mitigada pela simples existência de inquérito ou processo judicial em curso. Ademais, caso seja afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 em razão da existência de ação penal em curso e o Réu venha a ser nessa inocentado ulteriormente, a fundamentação desta sentença terá se baseado em fato não reconhecido pelo próprio Poder Judiciário, o que importaria em contradição na prestação jurisdicional.

Logo, ante a ausência de ao menos sentença condenatória em tal processo – com vistas a mitigar a presunção de inocência do Réu quanto ao envolvimento em associação criminosa –, inviável acolher o pedido de afastamento de causa minorante da pena nesta decisão, com base na existência de apenas uma ação penal em curso, cuja instrução sequer se encontra finalizada. Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, diante da reduzida quantidade da droga e das circunstâncias da prisão do agente. Fixo, portanto, a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP.

Considerando que o acusado preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado ao condenado cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR João Vitor Marques da Silva como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e

quatro) dias-multa, fixados em seu valor unitário mínimo, mediante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes acima explanados.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto, e a substituição por restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 40,00 (quarenta reais) (fl. 14), praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA